Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 32ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0084142-94.2023.8.17.2001**

AUTOR(A): MANUELA ALVES DE LIMA

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO

Vistos, etc.

MANUELA ALVES DE LIMA ajuizou ação pelo procedimento comum contra **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**, alegando que que é consumidora dos serviços da ré e necessita realizar tratamento com o medicamento Pertuzumabe (PERJETA), para a regressão da neoplasia de mama. Apesar de ter requerido o medicamento de forma administrativa, recebeu a resposta de que tal medicamento não teria cobertura contratual.

Concedida a tutela de urgência pretendida, a fim de que a demandada promova o fornecimento do medicamento nos exatos termos prescritos pelo médico assistente, sob pena de aplicação de multa diária, bem como de outras medidas coercitivas e sub-rogatórias (Id. 140222572).

Devidamente citada a demandada apresentou contestação (Id. 143053976). No mérito, alega que não existem dados concretos acerca da eficácia do medicamento em questão, bem como não está obrigada a fornecer o medicamento sem registro perante a ANVISA. Sustenta, ainda não ter praticado qualquer conduta capaz de ensejar ofensa ao patrimônio imaterial da autora. Pugna pela improcedência dos pedidos, bem como pelo afastamento de multa e da determinação de bloqueio de ativos.

Conforme decisão de Id. 144016161, foi afastado o pleito de suspensão da ordem, determinada a intimação da autora para manifestar-se acerca da contestação e oportunizada às partes a indicação das provas que pretendem produzir.

A parte demandada pugnou pela produção de prova pericial com especialidade em oncologia e/ou hematologia, com o fito de esclarecer as peculiaridades inerentes à indicação do medicamento Perjeta (pertuzumabe), Id.

146205635.

Determinada a constrição nas contas da executada, da soma de 6 meses de tratamento, devendo ser o montante liberado em favor da clínica ou instituição hospitalar responsável pelo cumprimento do tratamento. No mesmo ato, foi reiterada a determinação de intimação da parte autora para replicar a contestação e indicar provas que pretende produzir (Id. 146718035).

A demandante requereu a expedição de alvará em favor da clínica MULTIHEMO SERVIÇOS MÉDICOS S/A para a realização do ciclo, o que foi deferido na decisão de Id. 149785261, que determinou a expedição de alvará na soma de R$ 32.603,02 e aplicou nova multa na monta de 20% sobre o valor da causa ao demandado.

A parte ré informou sobre a interposição de novo agravo de instrumento (Id. 150519862).

Alvará expedido (Id. 149859002).

Por seu turno, a parte autora esclarece que, conforme laudo médico acostado aos autos, o tratamento mensal com o uso do fármaco é composto por três ciclos, da seguinte forma: 1ª semana - dosagem dobrada de 840mg no valor de R$ 32.603,02; 2ª semana – dosagem de 420mg no valor de R$ 16.901,51; 3ª semana – descanso; 4ª semana - dosagem de 420mg no valor de R$ 16.901,51. Requer, portanto, a complementação do valor já liberado, que corresponde a R$ 33.803,02 (trinta e três mil, oitocentos e três reais e dois centavos), para cobrir o 2º e 3º ciclos suficientes para a cobertura mensal.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

1. Do julgamento antecipado da lide.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do Art.355, I, do Diploma de Ritos. É que, compulsando os elementos produzidos pelas partes, se infere desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental apresentada. Eventual produção de prova oral ou pericial não terá o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde.

Encontra-se pacificado na doutrina e na jurisprudência que o julgador, visualizando nos autos elementos suficientes para a apreciação das questões postas pelas partes, pode dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, e julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa (Theotônio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 31ª Edição. São Paulo: Saraiva, p. 397).

Nessa diretiva, Cândido Rangel Dinamarco é preciso ao pontuar: “a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do Art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita

com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento" (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III. São Paulo: Malheiros, p.555).

Na mesma linha de raciocínio, o STF firmou entendimento de que "a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (STF - RE 101171, Relator Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984, p.20990). Para a Corte, "o propósito de produção de provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado (STF -RE 96725/RS, Rel. Min. Rafael Mayer).

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo caminho:

> AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, **não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção**. Desse modo, não há incompatibilidade entre o Art. 400 do CPC, que estabelece ser, via de regra, admissível a prova testemunhal, e o Art. 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).
>
> PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - **Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, Art.130, parte final).2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa**. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula n°7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe29/06/2011).

No tocante ao pedido de prova pericial formulado pela parte ré, cumpre ressaltar que realização de prova pericial médica para comprovar se o medicamento pleiteado não tem indicação para o tratamento da moléstia que acomete a autora (off label) afigura-se desnecessária, porquanto a imprescindibilidade da terapia oncológica com a utilização da medicação Pertuzumabe (PERJETA) é manifesta,

fundamentada no relatório médicos de Ids. 139509256, o qual se mostra suficiente na formação da convicção deste juízo, não havendo motivo para dilação probatória, porque totalmente desnecessária.

Aliás, médico assistente aponta no laudo que o tratamento prescrito foi indicado com base em estudo, tal como se extrai do relatório médico.

Sobre o uso de medicamento off label, cabe a menção da jurisprudência do STJ. Vejamos:

> RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO CLÍNICO OU CIRÚRGICO EXPERIMENTAL E MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE, EM SITUAÇÕES PONTUAIS. CONFUSÃO COM TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DESCABIMENTO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA, A RESPALDAR O USO. NECESSIDADE. 1. Por um lado, o art. 10, incisos I, V e IX, da Lei n. 9.656/1998, testilhando com a fundamentação da decisão recorrida, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. Por outro lado, no tratamento experimental, o intuito da pesquisa clínica não é propriamente tratar, mas alcançar resultado eficaz e apto ao avanço das técnicas terapêuticas atualmente empregadas, ocorrendo em benefício do pesquisador e do patrocinador da pesquisa. 2. O art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998, por tratar de questão atinente ao exercício profissional da medicina, deve ser interpretado em harmonia com o art. 7º, caput, da Lei n. 12.842/2013, que estabelece que se compreende entre as competências da autarquia Conselho Federal de Medicina - CFM editar normas "para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina", autorizando ou vedando sua prática pelos médicos. 3. Nessa linha, consoante deliberação do CFM, o uso off label justifica-se em situações específicas e casuísticas e ocorre por indicação médica pontual, sob o risco do profissional que indicou. É considerado como hipótese em que "o medicamento/material médico é usado em não conformidade com as orientações da bula, incluindo a administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de especialidades farmacêuticas registradas; indicações e posologias não usuais; administração do medicamento por via diferente da preconizada; administração em faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado; e indicação terapêutica diferente da aprovada para o medicamento/material". 4. Havendo evidências científicas que respaldem a prescrição, é universalmente admitido e corriqueiro o uso off label de medicamento, por ser fármaco devidamente registrado na Anvisa, aprovado em ensaios clínicos, submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância e produzido sob controle estatal, apenas não aprovado para determinada terapêutica. 5. Conforme propõe o Enunciado n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, devem as prescrições médicas consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, da posologia, do modo de administração, do período de tempo do tratamento "e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a

justificativa técnica". 6. Assim, como a questão exige conhecimento técnico e, no mais das vezes, subjacente divergência entre profissionais da saúde (médico assistente do beneficiário e médico-perito da operadora do plano), para propiciar a prolação de decisão racionalmente fundamentada, na linha do que propugna o Enunciado n. 31 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o magistrado deve "obter informações do Núcleo de Apoio Técnico ou Câmara Técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento especializado, tais como instituições universitárias, associações profissionais, etc". 7. A prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal, e nem mesmo a recorrente afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou que seja ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete. Portanto, e pela ausência de pedido de cassação da sentença para solicitação de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e/ou produção de prova pericial para demonstração da inexistência de evidência científica (clínica) a respaldar a prescrição do medicamento, é de rigor a confirmação da decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.729.566/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ. REsp n°2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, QUARTA TURMA). No mesmo sentido: RSTJ 102/500 e RT 782/302.

2. Mérito

A controvérsia dos autos reside em definir quanto à legalidade da negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente Pertuzumabe (PERJETA), bem assim se da negativa administrativa resultou dano extrapatrimonial indenizável.

A matéria trazida aos autos deve ser dirimida a luz dos parâmetros estabelecidos na Súmula nº 608, do C. STJ, segundo a qual, "**aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão**" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.04.2018, DJe17.04.2018; na mesma oportunidade, cancelou-se a Súmula nº 469).

Uma vez que a empresa requerida não fora constituída sob a modalidade autogestão, a análise solução da lide deverá ser informada pelos princípios e regras estabelecidos pela legislação consumerista.

Consoante entendimento consolidado pelo STJ, no entanto, "A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, **a Segunda Seção já pacificou que as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do Art. 35-G da Lei nº 9.656/1998**. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). No mesmo sentido

> “Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual. (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

Nessa diretiva, é certo que a Lei nº 9.656/98 traçou exigências mínimas para o fornecimento de medicamentos pelas operadoras de planos de saúde. Com efeito, o artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde excetua, nos incisos V e VI, o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos. Por sua vez, o artigo 12 inclui dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos antineoplásicos de uso domiciliar, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Eis a redação do Art. 10, incisos V e VI, da Lei de Planos de Saúde:

> "Art. 10. **É instituído o plano-referência de assistência à saúde**, **com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar**, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, **respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no Art. 12 desta Lei**, **exceto**: (...) V - **fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados**; VI - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar**, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do Art. 12; (...) § 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS." (grifou-se)

Ampliando a cobertura prevista no Art.10, o Art.12 consignou:

> Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do Art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o Art. 10, **segundo as seguintes exigências mínimas**: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) **cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes**; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) **cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral**, procedimentos radioterápicos para **tratamento de câncer e hemoterapia**, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da **assistência prestada em âmbito de internação hospitalar**;

Regulamentando a legislação federal neste aspecto particular, a Resolução Normativa (RN) nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conceituo medicamento importado não nacionalizado como aquele produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Por seu turno, medicamento de uso domiciliar, segundo o ente**

regulador, é aquele prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. A propósito, confira-se a redação do Art. 17, parágrafo único, V e VI, da RN nº 465/2021 da ANS:

> "Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no Art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998. Parágrafo único. **São permitidas as seguintes exclusões assistenciais**: (...) V - **fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA**; VI - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX**[1] **e X do Art. 18, e ressalvado o disposto no Art. 13**.

A exclusão da assistência farmacêutica para o medicamento importado sem registro na ANVISA encontra fundamento nas normas de controle sanitário. Isso porque a importação de medicamentos e outras drogas, para fins industriais ou comerciais, sem a prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde constitui infração de natureza sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei nº 6.360/1976 e 10, IV, da Lei nº 6.437/1977), não podendo a operadora de plano de saúde ser obrigada a custeá-los em afronta à lei (vide REsp nº 874.976/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009). Nesse sentido, os seguintes enunciados da I Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

> "Enunciado nº 6
>
> **A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados** na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei."
>
> "Enunciado nº 26
>
> **É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado**, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental."

De todo o arrazoado, portanto, colhe-se ser lícito que se exclua o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.

A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.

No caso em análise, ficou claro na prescrição médica e inclusive na bula da referida medicação que a administração do fármaco deverá ser efetivada com o auxílio de um profissional de saúde, o que exclui a tese de que tal medicamento é de uso domiciliar.

Inequívoco, portanto, o direito da parte autora ao tratamento que lhe foi sonegado.

A recusa manifestada pela ré afrontou a própria essência do contrato celebrado com a autora bem como a sua função social, na medida em que lhe subtraiu a possibilidade de ser tratada do mal que a acomete e que coloca em risco a sua vida. Frise-se que o contrato em questão é cativo de longa duração, os direitos e deveres assumidos pelos contratantes se protraem no tempo e, justamente em função disso, a autora possuía a justa expectativa de que, no momento em que mais necessitava dos serviços prestados pela seguradora ré, em razão da sua grave patologia, não lhe seriam opostos óbices ao tratamento de que necessitava.

Em casos análogos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco tem reconhecido a inequivocidade do direito do consumidor segurado:

> APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SPRAVATO 28 MG. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE DE ALTO RISCO. CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDMENTOS DA ANS. TRATAMENTO QUE DEVE SER REALIZADO DENTRO DA REDE CREDENCIA, SOB PENA DO REEMBOLSO SER EFETIVADO EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES ESTABELECIDOS NO CONTRATO, NO CASO DO SEGURADO OPTAR PELA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA, SEM PROCEDER À COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA QUE SE REVELA RAZOÁVEL NA HIPÓTESE. 1. O plano de saúde não pode se imiscuir na função médica acerca da indicação do tratamento mais adequado ao restabelecimento da saúde do paciente 2. **Independentemente do medicamento solicitado ser de uso ambulatorial, há que se observar tratar-se de fármaco devidamente registrado na ANVISA, já havendo o segurado se submetido a diversos tratamentos anteriores sem que tivesse obtido resposta terapêutica, acarretando um alto risco à vida do autor, ante o concreto planejamento suicida, atestado no laudo médico colacionado aos autos.** ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que compõem a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, DAR provimento parcial ao presente recurso, para determinar que o reembolso obedeça aos limites contratuais, no caso do segurado optar pela realização do tratamento fora da rede credenciada, bem como para reduzir a multa diária ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais). (TJ-PE–AI: 00121280420228179000, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGÍNIO, Data de Julgamento: 09/09/2022, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins).

2.1 Dos Danos Morais Alegados

Assiste razão à autora quando pugna por verba indenitária compensatória em razão dos danos morais resultantes de conduta da demandada.

O descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral. Entretanto, o agravamento da aflição psicológica do usuário de plano de saúde, que, para além da sua específica condição debilitada se vê abandonado e desguarnecido da proteção contratualmente acertada, inegavelmente configura hipótese de ofensa ao seu patrimônio imaterial.

Como já assinalado, o caso é de inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, respondendo a ré de forma objetiva perante o consumidor, nos termos do artigo 14 do código consumerista.

É consabido que a Política Nacional das Relações de Consumo objetiva atender às necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, a sua saúde e a sua segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia a elas inerentes, nos termos do Art. 4º, *caput* do CDC. Os princípios inerentes a essa política protecionista estão insculpidos nos diversos incisos do Art. 4º do CDC. Dentre eles evidencio: (i) o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (Art. 4º, I, do CDC); (ii) a harmonização dos sujeitos das relações de consumo, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio (Art. 4º, III, do CDC); (iii) a informação adequada, com vistas à melhoria do mercado de consumo (Art. 4º, IV, do CDC) e (iv) a coibição e à repressão eficiente de todos os abusos nele praticados (Art. 4º, VI, do CDC).

Nessa senda, associado ao exercício da livre iniciativa fundada em valores sociais (arts. 1º, IV; 170, *caput* e V; e 173, § 4º, da Constituição da República), é dever irrenunciável da demandada ser transparente e agir de boa-fé (objetiva), assegurando o equilíbrio nas relações de consumo com o atendimento das necessidades dos seus contratantes.

A proteção à saúde como direito básico dos consumidores é um dos sustentáculos da dignidade da pessoa humana constitucionalmente assegurada e dirige-se à realização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre eles, a liberdade, a justiça e a solidariedade.

Nesse contexto, quando a seguradora ré se nega a fornecer ou a autorizar, procedimentos, medicamentos, exames diagnósticos e materiais demandados pela equipe médica no período em que o segurado se encontra fragilizado física e psiquicamente em razão do adoecimento afigura-se como prática abusiva, fundada no abuso de poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao consumidor.

No caso em tela incide a teoria do risco do empreendimento que reclama responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC, evidenciada pela inobservância dos deveres de lealdade, transparência e boa-fé que devem nortear as relações de consumo, no cumprimento do contrato, de modo a acarretar transtornos capazes de ensejar ofensa ao patrimônio subjetivo do segurado.

A indevida negativa de autorização de procedimento, sem causa fática ou legal que a legitime, constitui abuso de direito que se amolda ao enunciado do artigo 186 do Código Civil e por isso é ato ilícito, ensejador de reparação através dos critérios compensatórios e sancionatórios, visando à recomposição do patrimônio moral violado, com base nos efeitos do ato lesivo, de modo a proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido.

A jurisprudência, com a qual me filio, em situações análogas não tem trilhado caminho diverso:

> DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONTRATUAIS CIVIS. **NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS THACOSIL E COLA BIOLÓGICA NECESSÁRIOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO**. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Tratando-se de entidade caracterizada pela autogestão e sem fins lucrativos, limitada a funcionários do Banco do Brasil S/A e seus parentes, ou seja, sem atuação no mercado de consumo, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 608.2. Todavia, ainda que afastada a aplicação do Código Consumerista, é fato que os princípios contratuais previstos na legislação civilista devem ser observados, notadamente a função social dos contratos (Art. 421) e os princípios da probidade e boa-fé objetiva (Art. 422), além da interpretação mais favorável ao aderente, em casos de contratos de adesão (Art. 423).3. Analisando as razões trazidas aos autos, entende este Colegiado que a tese defendida pelo plano de saúde apelante não é suficiente para justificar a não viabilização imediata do procedimento terapêutico requisitado, pois, considerando que a disponibilização de tratamentos médico-hospitalares necessários ao restabelecimento da saúde do segurado constitui a própria essência do contrato de seguro saúde, qualquer atitude tomada pela operadora de plano de saúde que obstaculize a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente, se mostra, a toda evidência, contrária à própria natureza do contrato, ameaçando seu objeto e o equilíbrio contratual, sendo, por isso, ilícita. 4. É obrigação da seguradora de saúde autorizar o serviço de saúde da maneira como requerido pelo médico assistente, por ser ele detentor de capacidade técnica para justificar a sua indicação e responsável por ponderar se o tratamento é capaz de influir na cura da paciente, podendo apenas o plano de saúde eleger que doenças estarão ou não abrangidas pela sua cobertura. Precedentes. 5. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no seu espírito. Casos de negativa de cobertura contratual por parte da operadora de saúde não pode ser visto como mero inadimplemento ou discussão contratual, caracterizando dano moral. Precedentes jurisprudenciais. 6. Constata-se que a parte ré, ora apelante, não trouxe informações capazes de rechaçar cabalmente as alegações do ator/apelado, não se desincumbindo de seu ônus probatório previsto pelo Art. 373, II, do CPC e sendo assim o reembolso integral das despesas contraídas pelo recorrido com o material cirúrgico deve ser deferido, tal como entendeu o juiz a quo não merecendo reparo sua decisão

no tocante aos danos materiais sofridos.7. Em sessão, deliberando-se acerca do quantum indenizatório e tomando por base os pressupostos de razoabilidade e proporcionalidade que devem permear a fixação da indenização por danos morais, considerou o Colegiado como razoável a redução do valor arbitrado em sentença para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 8. Recurso parcialmente provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE, Apelação Cível 0000092-19.2013.8.17.1280 (545551-4), Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior. Data do Julgamento: 05/02/2020). (Destaquei)

PLANO DE SAÚDE – SEGURADO – CONTRATO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – DESCONSIDERAÇÃO – Os contratos celebrados para assistência à saúde, se identificam como de prestação de serviço e devem obediência às regras do Código de Defesa do Consumidor no que respeita às cláusulas ditas abusivas, como o são aquelas que colocam o usuário do serviço em desvantagem exagerada em relação àquele que os presta; a inadimplência de sessenta dias que autoriza a suspensão do contrato é aquela é a contínua e não a que soma pequenos dias de atrasos alternados ocorridos ao longo do pacto. **Constatado que o segurado estava com suas prestações atualizadas, a recusa em atendê-lo quando necessitou do serviço, é certa que lhe acarretou prejuízos de natureza moral e material, esta, quando ele teve que desembolsar recursos próprios para tratar-se de sua enfermidade**; o dano material é o que ficou, objetivamente, provado, enquanto que o dano moral, que tem natureza subjetiva, deve ser arbitrado, segundo as circunstâncias do caso, suas consequências, partes envolvidas, tendo sempre presente que a condenação, que reverterá em favor do ofendido, tem caráter educativo, e, por isso, há que ser arbitrada de modo a não se revelar insignificante, e, por outro lado, não deve ser tão elevada para não se converter em locupletamento (TJMA – AC 019119/2002 – (44.287/2003) – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Stélio Muniz – J. 24.04.2003). (Destaquei)

Nesse cenário, a condenação da ré a compensar os danos de ordem imaterial suportados pela demandante se impõe, a partir de uma estimação prudencial que leve em consideração o grau em que o prejuízo causado influiu no seu ânimo e no seu sentimento:

A intensidade da culpa, a violência, as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso poderão informar o critério a ser adotado em tal arbitramento, árduo e delicado, porque entranhado de subjetividade. (TJRJ - 8ª C. - Ap. - Rel. Silveira Neto - j. 29.10.92 - JTJ- LEX 142/104).

A vítima de lesão de direitos de natureza não patrimonial (Constituição da República, Art. 5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP - 7º Rel. Campos Mello j. 30.10.91 RJTJESP 137/187).

A reparação, nesse panorama, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aquilatados de acordo com as peculiaridades que envolvem o pleito (STJ - RESP 200500465226 - (736968) - RJ - 4ª T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini - DJU 01.07.2005 - p. 00559).

Dito isto, em atenção aos critérios e princípios acima elencados e consideradas as peculiaridades do caso em comento, tenho que, diante das provas documentais constantes dos autos, houve perceptível inobservância da indispensável equidade da mesma no desenvolvimento do trato contratual avençado, propiciando plenas condições à respectiva ocorrência.

Concernente às repercussões do fato danoso, tenho-os como relevantes para abalar a personalidade da autora, principalmente por ocorrer no momento em que esta necessitava do devido respaldo econômico e de tranquilidade para se recuperar.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso em questão e tendo em vista os princípios de moderação e razoabilidade, entendo ser justo e necessário fixar o importe compensatório pertinente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo tal imposição plenamente justificável para que de um lado se tenha a devida compensação pelos transtornos passados pela autora e, de outro, medida verdadeiramente pedagógica, pois destinada a de tentar evitar a reiteração da conduta perpetrada pela demandada, explicitamente prejudicial aos seus contratantes, consumidores.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão entabulada na exordial para, confirmando a tutela deferida em sede de agravo, **CONDENAR** a empresa ré a: (i) ao fornecimento do medicamento **Pertuzumabe (PERJETA)** à autora, na forma prescrita pelo seu médico, sob pena de aplicação de multa diária, bem como de outras medidas coercitivas e sub-rogatórias e; (ii) pagar, a título compensatório pelos danos morais impostos ao autor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser atualizado pelos índices da tabela de referência da Justiça Estadual, a partir da sua fixação, acrescido de juros moratórios de 1% a partir da citação.

Condeno a demandada a pagar custas e honorários advocatícios que ora fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 2º do CPC.

No caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado), aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Interposta a apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC, que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (Art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal.

- Da efetivação da tutela de urgência deferida nos autos

Considerando que a ordem mandamental urgente, necessária ao tratamento de saúde e, de conseguinte, à preservação da vida da autora, não vem sendo cumprida espontaneamente, convém seja dado prosseguimento às ulteriores providências visando a efetivação da tutela de urgência deferida nos autos.

Foi determinada a constrição nas contas da executada, da soma de 6 meses de tratamento, devendo ser o montante liberado em favor da clínica ou instituição hospitalar responsável pelo cumprimento do tratamento (Id. 146718035).

Alvará expedido no valor de R$ 32.603,02, para a cobertura de um ciclo mensal (Id. 149859002).

Por seu turno, a parte autora esclarece que, conforme laudo médico acostado aos autos, o tratamento mensal com o uso do fármaco é composto por três ciclos, da seguinte forma: 1ª semana - dosagem dobrada de 840mg no valor de R$ 32.603,02; 2ª semana – dosagem de 420mg no valor de R$ 16.901,51; 3ª semana – descanso; 4ª semana - dosagem de 420mg no valor de R$ 16.901,51. Requer, portanto, a complementação do valor já liberado, que corresponde a R$ 33.803,02 (trinta e três mil, oitocentos e três reais e dois centavos), para cobrir o 2º e 3º ciclos suficientes para a cobertura mensal.

Nesse passo, revela-se necessária a expedição de novo alvará para complementar o tratamento mensal, visando a cobertura do 2º e 3º ciclos, no valor total de R$33.803,02 (trinta e três mil, oitocentos e três reais e dois centavos), conforme orçamento já anexado aos autos.

Destarte, expeça-se, de imediato, em favor da clínica MULTIHEMO SERVIÇOS MÉDICOS S/A alvará na soma de R$33.803,02 (trinta e três mil, oitocentos e três reais e dois centavos), referente à complementação do tratamento mensal. Nesta mesma oportunidade, ratifico a imposição de multa na monta de 20% sobre o valor da causa ao demandado.

Expedida a ordem de pagamento, terá a demandante o prazo de 10 dias **corridos para comprovar nos autos a destinação da quantia levantada, através de documentos fiscais e contratuais idôneos, acompanhados de recibo. No mesmo prazo, deverá apresentar laudo atualizado do tratamento necessitado, indicando as datas e a quantidade de ciclos ainda previstas.**

Diante da informação de interposição de agravo de instrumento, comunique-se ao juízo *ad quem* sobre o julgamento ora lançado, para que seja avaliada a hipótese de perda do objeto do recurso manejado.

Cumpra-se, com prioridade.

Publique-se e intimem-se.

Certificado o trânsito, arquivem-se os autos definitivamente.

Via eletronicamente assinada servirá como expediente de comunicação processual.

Recife (PE), data da assinatura eletrônica.

José Júnior Florentino dos Santos Mendonça

Juiz de Direito

2

---

[1] Art.18, IX, da Resolução Normativa 465/2021, da ANS: "(...) IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características(...)."

Assinado eletronicamente por: JOSE JUNIOR FLORENTINO DOS SANTOS MENDONCA
09/12/2023 12:16:08
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 154620601

23120912160793100000151029324

IMPRIMIR GERAR PDF